

1506100-43.2021.8.26.0362

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... preceito legal. A esse respeito:

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1506100-43.2021.8.26.0362 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506100-43.2021.8.26.0362

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

JOÃO PEDRO DA VEIGA JÚNIOR e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

João Pedro da Veiga Junior, menor de 21 anos, foi denunciado e está sendo processado, porque no dia 14 de dezembro de 2021, por volta das 14h30min, na Avenida Flamboyant, altura do numeral 753, Jardim Guaçuano, neste Município e Comarca de Mogi Guaçu, nas imediações de praças públicas e de estabelecimentos de ensino, vendeu e entregou 02 (dois) microtubos contendo cocaína, pesando um grama, a Celso Aparecido de Moraes, bem como guardava e mantinha em depósito, para fins de tráfico e entrega a terceiros, outros 06 (seis) microtubos contendo cocaína, pesando 1,6 gramas, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, e o fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi notificado (fls. 142), apresentou defesa prévia (fls. 112/116) e a denúncia foi recebida aos 03 de fevereiro de 2022 (fls. 125/127).

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado.

A representante do Ministério Público pugna pela procedência da ação penal e condenação do acusado nos termos descritos pela denúncia.

A defesa requer a improcedência da ação penal, com consequente absolvição do réu.

Requer benesses quanto à pena aplicável.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDIDO.

No mérito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10/11); pelo auto de constatação provisória de substância tóxica (fls. 12/13), pelo laudo pericial do local (fls. 163/168); pelos laudos periciais de exame químico-toxicológicos (fls. 62/64 e 65/67) e por toda a prova oral colhida em juízo.

O policial civil Rodolfo Luís Caetano disse que estava monitorando a Avenida dos Flamboyant, nesta cidade, e passou a observar a movimentação. No local, presenciou a troca de objetos em quatro ocasiões. Acionou o policial Juliano, para realização da abordagem. Localizou dinheiro com o acusado e abordou também Celso, com quem apreendeu dois pinos de cocaína e ele confirmou a aquisição da droga. No arbusto onde viu o acusado se deslocando, localizou mais seis porções de cocaína. Monitorou o acusado apenas nesta data, permanecendo trinta a quarenta minutos no local.

O policial civil Carlos Juliano Martins disse que foi feito monitoramento no local pelo policial Rodolfo, que ocupava viatura descaracterizada. Disse que foi acionado por seu colega e deteve o acusado, sendo que Rodolfo abordou o usuário, com quem apreendeu dois pinos de cocaína, bem como outros seis pinos na base de uma árvore.

Em solo policial, Celso Aparecido de Moraes disse que há cerca de um ano que é dependente químico, usuário de cocaína. O declarante, já tendo informações de que no local dos fatos é ponto de comércio de drogas, se dirigiu para tal local, com o intuito de adquirir cocaína para o seu uso pessoal. Chegando ao local, deparou com a pessoa do autuado João Pedro, fazendo comércio de drogas por aquele local. De imediato, conversou com o acusado e comprou do mesmo dois microtubos de cocaína, e pagou pela droga o valor total de vinte reais (fls. 08).

O acusado João Pedro da Veiga Júnior disse que os fatos são verdadeiros. Informa que enfrentava dificuldades financeiras e começou a vender drogas na semana anterior. Disse que vendia duzentos reais por dia e auferia quarenta reais.

Com efeito, o depoimento prestado pelos policiais civis é digno de toda credibilidade, já que devidamente compromissados e inexistentes indícios de interesse dos servidores públicos em prejudicar pessoa inocente. De acordo com a jurisprudência:

PROVA - Depoimento policial - Eficácia - Mera condição de agente público que não torna a testemunha impedida ou suspeita - Precedentes - Recurso improvido.

(Apelação Criminal n. 974.712-3/9-00 - Santos - 14ª Câmara Criminal - Relator:

Sérgio Ribas - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 4.191).

PROVA - Depoimento policial - Valor - Credibilidade e responsabilidade equivalentes à palavra dos civis, máxime quando corroboradas pelo conjunto probatório -

Precedentes - Recurso improvido. (Apelação Criminal n. 497.707-3/9-00 - Santos - 5ª Câmara Criminal - Relator: Marcos Zanuzzi - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 13.332).

No caso dos autos, as provas carreadas permitem a formação da convicção de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico, em razão da versão apresentada pelo policial civil Rodolfo, que contou que visualizou o acusado efetuar a troca de objetos com quatro diferentes indivíduos nos minutos em que permaneceu no local. De se destacar que o depoimento prestado por Celso, na fase policial, está em sintonia com o relato apresentado por Rodolfo nesta data.

Se tudo isso não bastasse, o próprio acusado confessou que vendia drogas no local há uma semana, de modo que a prova colhida é suficiente e implica na condenação do acusado nos exatos termos da denúncia.

Bem de ver que o tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06 é misto alternativo, de modo que, comprovado que o acusado vendeu e guardava porções de cocaína acondicionadas de forma fracionada, deve ser dado como incursão naquele preceito legal. A esse respeito:

“O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente” (RT 776/663).

"Ademais, é sabido que o tráfico de entorpecentes é delito de ação múltipla ou conteúdo variado cuja consumação se contenta com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou simples porte da droga, desde que não seja para consumo pessoal. Daí não haver falar em mero auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi flagrada na posse de maconha e cocaína. (STJ, HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 31/08/2011).

No mais, não há que se duvidar do relato dos policiais, pois o próprio acusado disse que nada tinha contra eles, não se vislumbrando nenhum indício para imputarem falsamente o crime ao acusado.

Passo à dosagem da pena, em conformidade com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Em primeira fase, as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, de modo que fixo a pena privativa de liberdade em seu patamar mínimo, isto é, em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Em segunda fase, estão presentes as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, vez que o acusado era menor de 21 anos da data dos fatos, anotando-se que a reprimenda não pode ser reduzida aquém do mínimo legal (súmula 231 do STJ).

Em terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da lei n. 11.343/06, já que o laudo pericial (fls. fls. 163/168) revela que nas imediações do local onde os fatos ocorreram existem estabelecimentos de ensino e praça pública, o que evidentemente facilita a propagação do tráfico de drogas devido ao maior fluxo de pessoas.

Aliás, a lei não exige que aqueles sejam os locais especialmente visados pelo infrator, bastando a proximidade física. A esse respeito:

A traficância era exercida em local inequivocamente próximo das escolas "Zumira" e "Rubens Leme Asprino" (distava aproximadamente 800 metros da primeira e 490 metros da segunda - vide fls. 74/7), sendo que para a incidência da majorante referente ao artigo 40, inciso III, não exige a lei que o estabelecimento de ensino seja especialmente visado pelo infrator, bastando, tão somente, a proximidade física e o conhecimento dessa proximidade. (TJSP, Apelação n. 0004114-44.2011.8.26.0083, Relator Des. Geraldo Wohlers, julgado aos 26.2.2013, 3ª Câmara de Direito Criminal) Ainda sobre essa questão, o Col. Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se pronunciar no sentido de que "(...) O tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, independente de os agentes visarem ou não os frequentadores daquele local (...). Destarte, não procede a alegação da impetrante no sentido de que não há demonstrativo de relação evidente entre a conduta dos pacientes e as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos ensino, uma vez que é irrelevante o fato de haver ou não intenção dos acusados de atingir os frequentadores do estabelecimento. Para incidência da mencionada causa de aumento de pena, basta a proximidade física do local onde o tráfico estava sendo praticado e o estabelecimento de ensino, o que ficou corretamente assentado pelas instâncias ordinárias." (HC 116.929/SP, 1ª Turma, relator Min. Luiz Fux, julgado aos 15.10.2013).

No mesmo sentido, posiciona-se o E. Superior Tribunal de Justiça, que em precedente desta Comarca decidiu que: No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento no sentido de ser desnecessária, para a incidência da majorante do artigo 40, III, da lei de drogas, a comprovação de que o comércio de ilícito de substâncias entorpecentes vise atingir os alunos do estabelecimento, bastando, para sua incidência, que a prática da traficância tenha ocorrido nas imediações da escola (RESP n. 1.774.414/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22.2.2019).

Por estes fundamentos, majoro a pena em 1/6, resultando pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias multa.

Ainda em terceira fase, inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, pois o policial civil afirmou que monitorou o local por 40 minutos e visualizou o acusado efetuar a venda de drogas a quatro pessoas diversas.

Além disso, o próprio acusado informou que vendia drogas no local há uma semana, e que as transações geravam duzentos reais, de modo que não estão presentes os

requisitos dispostos no artigo 33, § 4º, da lei n. 11.343/06.

Isso porque o dispositivo exige que o agente não se dedique a atividades criminosas, o que não se pode dizer do agente que efetua quatro vendas de drogas em quarenta minutos e praticava o comércio há uma semana no local do fato, circunstâncias que demonstram que o acusado ostenta envolvimento em atividades criminosas.

Por essa razão, o agente não faz jus ao benefício destinado a iniciantes na seara delitiva, razão pela qual fica afastada a aplicação da minorante mencionada.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal.

De acordo com o total de pena imposta e porque favoráveis as circunstâncias judiciais, o regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto. Nesse sentido: AGRADO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS.

APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.

IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. REGIME FECHADO COM BASE NA HEDIONDEZ DO DELITO. DESCABIMENTO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 44, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRADO REGIMENTAL

DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agrado regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - In casu, v. acórdão impugnado fundamentou o afastamento do

tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava a atividades criminosas (tráficação), em razão não somente pela quantidade de drogas apreendidas, mas também pelas circunstâncias em que se deu a prisão, bem como constatarem que não se tratava de traficante ocasional. Tudo isso, são elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição, como reclama a impetrante, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. III - Considerada a quantidade de pena aplicada (5 anos de reclusão), bem como fixada a pena-base no mínimo legal, em virtude da análise favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, constata-se a existência de constrangimento ilegal decorrente da imposição do regime fechado, de sorte que o paciente faz jus ao regime inicial semiaberto, o qual se revela como o mais adequado à prevenção e à repressão do delito em tela, conforme o art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. IV - Mantida a pena cominada ao paciente em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, resta prejudicado o pedido de substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos, pois não preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 44 do Código Penal. Agrado regimental desprovido.

(....)

No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, insta consignar que o Pleno do eg. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 111.840/ES, por maioria de votos, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, com a nova redação dada pela Lei n. 11.464/2007, por ofender a garantia constitucional de individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal). Afastou, dessa forma, a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para os condenados pela prática de crimes hediondos e dos demais delitos a eles equiparados. Em tal contexto, nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o Julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e, em se tratando dos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, como no caso, deverá levar em conta a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). Na hipótese, verifica-se nos excertos acima colacionados que o v. acórdão impugnado manteve o regime prisional fechado, amparando-se tão somente na hediondez do delito (tráfico de drogas), sem indicar elementos concretos dos autos que demonstrassem a real necessidade de imposição de regime prisional mais gravoso, o que vai de encontro ao

teor dos Enunciados ns. 718 e 719 da Súmula do STF, bem como do Enunciado n. 440 da Súmula do STJ, que assim dispõem:
(....)

Sob essa perspectiva, considerada a quantidade de pena aplicada (5 anos de reclusão), bem como fixada a pena-base no mínimo legal, em virtude da análise favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, constata-se a existência de constrangimento ilegal decorrente da imposição do regime fechado, de sorte que o paciente faz jus ao regime inicial semiaberto, o qual se revela como o mais adequado à prevenção e à repressão do delito em tela, conforme o art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. (Superior Tribunal de Justiça, AgRg no HABEAS CORPUS Nº 604.250 - SP, julgado aos 6/10/2020, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma)
Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do total da pena imposta.

Por estas razões, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO João Pedro da Veiga Júnior à pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 583 dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando-o como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, da Lei nº 11.343/06.

O réu respondeu ao processo no cárcere e com a condenação ficam reforçados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, razão pela qual lhe nego o direito de recorrer em liberdade, anotando, ainda, que o crime de tráfico de droga atenta contra a ordem pública, fustigada pelo avassalador crescimento dessa prática espúria. Recomende-se na prisão, com expedição de ofício.

Deixo de aplicar o quanto disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, pois o acusado não atingiu o lapso temporal para eventual progressão de regime. Decreto o perdimento do numerário apreendido na posse do acusado, pois não comprovada sua origem lícita e porque consequência lógica da condenação imposta. Oficie-se ao FUNAD após o trânsito em julgado.

Expeça-se certidão de honorários à patrona dativa nos termos do Convênio OAB-Defensoria.

Custas ex lege, observada eventual gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

PRI.

Mogi Guacu, 24 de março de 2022.

Paulo Rogério Malvezzi

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA